

LA CLÁUSULA PENAL

a) Nociones previas

671. Concepto.— La cláusula penal es un instituto polivalente: proporciona un incentivo para la conducta debida del deudor, esto es el cumplimiento específico de su obligación (función compulsiva o estimulativa), y fija de antemano el monto indemnizatorio para el caso de incumplimiento (función indemnizatoria), sea éste definitivo (cláusula penal compensatoria) o temporario (cláusula penal moratoria).

Esa que en que una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación, y esta pena o multa entra en lugar de la indemnización de perjuicios e intereses, cuando el deudor se hubiese constituido en mora.

673. Funciones.— La cláusula penal cumple, sustancialmente, dos funciones:

(1) Función compulsiva. La función compulsiva o estimulativa de la cláusula penal está prevista para incentivar el cumplimiento. El primer deber del deudor frente a la obligación es cumplirla, y se desvanecería la finalidad ética de la cláusula penal si se la concibiera exclusivamente en su otra función indemnizatoria.

(2) Función indemnizatoria. La cláusula penal tiene, además, una función indemnizatoria, que se superpone a la anterior o la desplaza, y rige aunque no haya perjuicio para el acreedor. Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno.

675. Clasificación.— Existen dos especies de cláusula penal:

- (1) Compensatoria, que es debida en caso de inexecución definitiva; y
- (2) Moratoria, que juega en el caso de inexecución temporaria.

676. Caracteres.— La cláusula penal presenta los siguientes caracteres

- (1) Es accesoria
- (2) Es subsidiaria, lo cual significa que reemplaza a la prestación incumplida.
- (3) Es condicional, y el hecho condicionante que la sujeta es el incumplimiento del deudor.
- (4) Es estipulable a favor del acreedor o de un tercero.
- (5) Es relativamente inmutable.

678. Objeto.— La cláusula penal sólo puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones.

679. Funcionamiento.— La indemnización convenida como cláusula penal es debida desde la mora del deudor, sea que aquélla actúe como compensatoria o como moratoria.

Cuando se trata de la pena compensatoria el acreedor puede, “a su arbitrio”, demandar la ejecución de la obligación principal, o el pago de la pena.

Inmutabilidad

693. Antecedentes. Derecho comparado.— Uno de los caracteres que define a la cláusula penal es la inmutabilidad: en principio, el acreedor no puede alegar útilmente que la pena es insuficiente, ni el deudor se puede liberar de pagarla arguyendo que excede el efectivo daño irrogado por su incumplimiento. Éste carácter responde adecuadamente a los intereses del acreedor y del deudor, y se explica porque la cláusula penal fija a forfait el monto indemnizatorio.

697. Los jueces podrán, sin embargo, reducir las penas cuando por su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuren un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor. El sistema es el de inmutabilidad relativa.

Presupuestos de reducibilidad de la cláusula penal. —

(1) Primer presupuesto: la pena desproporcionada. La pena debe ser de “monto desproporcionado”. La desproporción debe ser ponderada a tenor de estas pautas: I) la gravedad de la falta; II) el valor de las prestaciones; y III) las demás circunstancias del caso.

I) La gravedad de la falta parece aludir a la culpa, de lo que cabe extraer que se ha ponderado el sentido de la conducta, el grado de reproche que merece el incumplidor.

Pero está también implicada la gravedad de la infracción del contrato: es distinto el caso del deudor que viola una obligación permanente alguna vez, de aquel que lo hace sistemáticamente.

II) Debe ser considerado además el valor de las prestaciones. Se trata de todo interés legítimo que tenga el acreedor en el cumplimiento de la obligación por el deudor, sea patrimonial o extrapatrimonial.

De allí, verbigracia, que no se pueda reputar desproporcionada la cláusula penal que prevea el pago de fuerte suma de dinero para el caso de ser incumplido un contrato estipulado para satisfacer intereses de afección del acreedor.

III) Han de ser computadas, asimismo, las demás circunstancias del caso, lo cual implica notoriamente a la noción de equidad.

Cabe señalar, entre ellas, las ventajas que supone para el deudor el incumplimiento en que incurre, y hasta la situación económica y solvencia de las partes, sobre todo la del deudor.

700.— (2) Segundo presupuesto: La lesión subjetiva. La desproporción del monto de la pena no basta por sí para justificar su reducción judicial. Debe, asimismo, configurar un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

704. Caso de cumplimiento parcial o irregular.— Si el deudor cumple sólo una parte de la obligación, o la cumple de un modo irregular, o fuera del lugar o del tiempo a que se obligó, y el acreedor la acepta, la pena debe disminuirse proporcionalmente, y el juez puede arbitrarla si las partes no se conviniesen.

Carácter accesorio

707. Principio.— La cláusula penal es accesorio, de manera que la rige el principio *accessorium suum sequitur* principal (lo accesorio sigue la suerte de lo principal).

Carácter subsidiario

710. Principio.— En principio la cláusula penal es subsidiaria del cumplimiento de la obligación principal, pues entra a jugar en lugar de ésta.

Regulación de la Cláusula penal en el Código Civil y Comercial de la Nación:

ARTICULO 790.- Concepto. La cláusula penal es aquella por la cual una persona, para asegurar el cumplimiento de una obligación, se sujeta a una pena o multa en caso de retardar o de no ejecutar la obligación.

ARTICULO 791.- Objeto. La cláusula penal puede tener por objeto el pago de una suma de dinero, o cualquiera otra prestación que pueda ser objeto de las obligaciones, bien sea en beneficio del acreedor o de un tercero.

ARTICULO 792.- **Incumplimiento.** El deudor que no cumple la obligación en el tiempo convenido debe la pena, si no prueba la causa extraña que suprime la relación causal. La eximente del caso fortuito debe ser interpretada y aplicada restrictivamente.

ARTICULO 793.- **Relación con la indemnización.** La pena o multa impuesta en la obligación suple la indemnización de los daños cuando el deudor se constituyó en mora; y el acreedor no tiene derecho a otra indemnización, aunque pruebe que la pena no es reparación suficiente.

ARTICULO 794.- **Ejecución.** Para pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor puede eximirse de satisfacerla, acreditando que el acreedor no sufrió perjuicio alguno.

Los jueces pueden reducir las penas cuando su monto desproporcionado con la gravedad de la falta que sancionan, habida cuenta del valor de las prestaciones y demás circunstancias del caso, configuran un abusivo aprovechamiento de la situación del deudor.

ARTICULO 795.- **Obligaciones de no hacer.** En las obligaciones de no hacer el deudor incurre en la pena desde el momento que ejecuta el acto del cual se obligó a abstenerse.

ARTICULO 796.- **Opciones del deudor.** El deudor puede eximirse de cumplir la obligación con el pago de la pena únicamente si se reservó expresamente este derecho.

ARTICULO 797.- **Opciones del acreedor.** El acreedor no puede pedir el cumplimiento de la obligación y la pena, sino una de las dos cosas, a su arbitrio, a menos que se haya estipulado la pena por el simple retardo, o que se haya estipulado que por el pago de la pena no se entienda extinguida la obligación principal.